

刑法
No102

共通問題 R5-12

(配点：2)

月 日

月 日

緊急避難に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産という個人的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為に成立するものであるから、国家的法益に対する危難を避けるためにした行為に緊急避難が成立することはない。

イ. 避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、両者が同程度の場合にも、緊急避難は成立し得る。

ウ. 緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。

エ. 過剰避難が成立する場合、情状によって、その刑を減輕することはできるが免除することはできない。

オ. 緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、正当防衛におけるのと同様に、手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであれば足りる。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No102	緊急避難	正答率
共通R5-12	正 解	91%
	3	

ア 誤っている

最判昭24.8.18は、正当防衛及び緊急避難の成否が争われた事案において、「国家的、国民的、公共の法益についても正当防衛の許さるべき場合が存する」とした上で、「本来国家的、公共の法益を保全防衛することは、国家又は公共団体の公的機関の本来の任務に属する事柄であつて、これをたやすく自由に私人又は私的団体の行動に委すことは却つて秩序を乱し事態を悪化せしむる危険を伴う虞がある。それ故、かかる公益のための正当防衛等は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合においてのみ例外的に許容さるべきものと解するを相当とする」というように、緊急避難についても正当防衛と同列に考えられている。よって、国家的法益に対する危険を避けるためにした行為についても緊急避難が成立し得る。

イ 正しい

37条1項は、緊急避難の要件として、「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」という、法益の権衡の要件を規定している。これは、「正」対「正」の対立である緊急避難の場合は、生じた害すなわち侵害法益が、避けようとした害すなわち保全法益の程度を超えなかった場合に限り正当化されるということを意味する。その趣旨は、価値が衝突していずれかが否定されざるを得ない場合には、社会全体の見地から、大きい価値を選択することにある。そして、「超えなかった場合」という文言にも表れているとおり、法益が同価値の場合も正当化される。よって、避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、両者が同程度の場合にも、緊急避難は成立し得る。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

最判昭24.8.18は、正当防衛及び緊急避難の成否が争われた事案において、「刑法36条にいわゆる急迫の侵害における『急迫』とは、法益の侵害が間近に押し迫つたことすなわち法益侵害の危険が緊迫したことを意味するのであつて、被害の現在性を意味するものではない」とした上で、「また刑法37条にいわゆる『現在の危険』についても、ほぼこれと同様のことが言い得る」としている。よって、緊急避難における「現在の危険」には、危険が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。

エ 誤っている

37条1項ただし書は、過剰避難が成立する場合、「情状により、その刑を減輕し、又は免除することができる。」と任意的減免を規定している。よって、過剰避難が成立する場合は、減輕のみならず免除も可能である。

オ 誤っている

最判昭44.12.4、最大判昭24.5.18。正当防衛における「やむを得ずにした行為」とは、「急迫不正の侵害に対する反撃行為が、自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであること、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであることを意味する」（最判昭44.12.4）一方、緊急避難における「やむを得ずにした行為」とは、「当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する」（最大判昭24.5.18）。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。